

1500492-51.2020.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... informações no sentido de que estava havendo tráfico na casa do NILO. No local, o réu e Marcos Scravone foram abordados na frente do imóvel. NILO estava em poder de 01 porção de "crack" e com Marcos havia dinheiro (R\$150,00). Indagados, ambos confessaram informalmente a prática do tráfico. NILO autorizou o ingresso dos policiais em seu imóvel, local em que, com a ajuda dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500492-51.2020.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500492-51.2020.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2110244/2020 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 11255989 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 636/20/935 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 2110244 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 636/20/935 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NILO MINEIRO FILHO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

NILO MINEIRO FILHO, devidamente qualificado nos autos (fl. 13), foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusado de ter, no dia 05 de maio de 2020, por volta das 11h00m, na Rua Rondônia, 93, Jardim Brasil, nesta cidade e Comarca, trazido consigo e

guardado, para inequívocos fins de comercialização, 77 (setenta e sete) porções de "maconha", pesando 235,1g e 01 (uma) porção de "crack", pesando 0,2g, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 122/124).

Prisão flagrancial convertida em preventiva (fls. 78/80).

O réu foi solto por decisão do E. TJSP, exarada em sede de habeas corpus impetrado (fls. 98/100).

Alvará cumprido (fls. 107/110).

A denúncia foi recebida em 03.06.2020 (fl. 125).

Devidamente citado (fl. 150), o acusado, por intermédio de sua D. Defensora nomeada (fl. 159), apresentou resposta por escrito à acusação (fls. 165/167), arrolando testemunhas comuns.

Não sendo o caso de julgamento in limine do feito, com a absolvição sumária do acusado, determinou-se a abertura da fase instrutória (fl. 176), oportunidade em que foi colhida a prova oral, consistente nas oitivas das duas testemunhas arroladas em comum, seguindo-se do interrogatório do acusado, tudo pelo sistema audiovisual (cf. ata de fl. 218).

Em sede de memoriais escritos, o D. Promotor pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, por entender suficientemente provadas a autoria e a materialidade delitiva (fls. 226/230). A D. Defensora, por sua vez, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e da figura do tráfico privilegiado, tecendo, ainda, considerações a respeito da pena e do regime prisional (fls. 233/238).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DECLARO preclusa a instauração de incidente de dependência químico-toxicológico ou insanidade mental do acusado, frente a não apresentação, pela D. Defensora (fl. 222), apesar de lhe ter sido facultado ao término da audiência (fl. 218), de indícios mínimos no sentido de que o réu, ao tempo do fato, apresentasse comprometimento em seus aspectos volitivo e/ou intelectual, que pudessem implicar no reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

Ao tempo do seu interrogatório observou-se muito mais uma frágil tentativa de ludibriar este julgador, do que propriamente confusão mental.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade da infração está devidamente comprovada por meio dos autos de exibição e apreensão (fls. 64/66) e de constatação provisória (fl. 12), ilustrado com fotos (fls. 32 e 33), pelo comprovante do numerário depositado (fl. 115), bem como e, principalmente, pelos laudos dos exames químico-toxicológicos realizados nas substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 144/146 e 147/149).

Com efeito, os referidos laudos, corroborando o auto de constatação preliminar, confirmaram tratar-se de cocaína como princípio ativo do "crack" e "maconha" - com a presença do THC -, substâncias entorpecentes que causam dependência física ou psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 - SVS/MS.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

Vale lembrar, em primeiro lugar, que o réu foi preso em flagrante, trazendo consigo

e guardando drogas, cuja quantidade e forma de acondicionamento, além das circunstâncias fáticas em que estava inserido, indicarem a prática da mercancia, razão pela qual a autoria torna-se certa, pois, segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho, a prisão em flagrante "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra "Do Flagrante Delito", 1933, p. 25.

De acordo com HÉLIO TORNAGHI, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" ("Curso de Processo Penal", 5ª ed., 49).

Ademais, a análise coligida dos depoimentos colhidos no caderno investigativo e produzidos sob o crivo do contraditório autoriza concluir pela responsabilidade penal do réu. Vejamos.

José Eduardo Rocha, policial militar, relatou que na data dos fatos estava de serviço, quando recebeu uma "denúncia" informando que NILO estava traficando em sua residência. Na posse do endereço, se dirigiu até o local, surpreendendo o réu na via pública, nas imediações da residência, na companhia da pessoa identificada como Marcos Scravone, sendo ambos abordados. Em poder do réu foi encontrado uma porção de "crack" e com o outro indivíduo certa quantia em dinheiro (R\$151,00). Indagados, eles confessaram informalmente a prática de tráfico no local. NILO ainda informou que possuía mais drogas em seu imóvel, autorizando o ingresso dos policiais. Com o ajuda do canil da GCM, tubos, contendo entorpecentes (27 e 50 porções), foram localizados enterrados, além de R\$1.400,00 em dinheiro e apetrechos.

Cristiano Roberto Cimenton, colega de farda, confirmou estar de serviço e ter recebido informações no sentido de que estava havendo tráfico na casa do NILO. No local, o réu e Marcos Scravone foram abordados na frente do imóvel. NILO estava em poder de 01 porção de "crack" e com Marcos havia dinheiro (R\$150,00). Indagados, ambos confessaram informalmente a prática do tráfico. NILO autorizou o ingresso dos policiais em seu imóvel, local em que, com a ajuda dos cães farejadores da GCM, foram localizados tubos de pvc enterrados, contendo drogas em seus interiores, tratando-se de porções de "maconha" (27 e 50), acondicionadas prontas para comercialização. No interior do imóvel também foram apreendidos mais valores em espécie, além de balança digital, tesoura e embalagens usadas para acondicionar entorpecentes.

Silente na fase policial (fl. 05), interrogado em juízo, NILO negou a prática dos fatos. Alegou que naquela data estava dentro de casa, dormindo, quando os policiais nela ingressaram e o prenderam por tráfico. Não foram encontradas drogas em seu imóvel naquele momento. O dinheiro apreendido é fruto do seu trabalho como pedreiro.

Pois bem. Este é o contexto instalado nos autos.

Não se sabe sob qual ângulo probatório a D. Defesa entendeu que o réu confessou a prática dos fatos, tal como sustentou nos memoriais escritos apresentados, dedicando dois tópicos idênticos ao tema (fls. 235/236 e 237).

Ouvido em audiência e indagado pontualmente por este Julgador quanto a aparente contradição em seu relato (a partir dos 19m45s), NILO sustentou que já guardou drogas em sua casa para terceira pessoa (Rafael), mas negou que aquelas localizadas pelos cães farejadores, no interior de tubos, enterrados no jardim, e apreendidas pelos policiais, estivessem ali naquela ocasião (20m08s).

De outro canto, os policiais bem destacaram o recebimento de informações veiculando que no imóvel do réu estava ocorrendo a prática do crime de tráfico e para lá se

dirigiram. Então, surpreenderam NILO na companhia de Marcos Scravone, ambos juntos, defronte ao imóvel alvo da "denúncia" anônima. Abordados, uma porção de "crack" foi encontrada com NILO (fl. 32), além de certa importância em dinheiro com Marcos Scravone.

Questionados, houve a confissão informal de que estariam comercializando drogas e, com a autorização de NILO, proprietário do imóvel, houve o ingresso dos milicianos, de forma que com a ajuda dos cães farejadores, treinados pela Guarda Municipal de Amparo, foram localizados dois tubos de pvc enterrados na área do imóvel, contendo 27 e 50 porções de "maconha", individualmente embaladas, prontas para comercialização (vide foto de fl. 33).

E, quanto à autorização, o próprio réu, proprietário daquele imóvel, franqueou a entrada dos policiais, não sendo crível que os milicianos tenham invadido o imóvel e o detido antes mesmo de encontrarem os entorpecentes enterrados.

Ademais, se mostrava desnecessária a prévia autorização, frente às informações anteriormente recebidas, a abordagem de NILO, defronte ao imóvel, em atitude suspeita e com drogas, além da sua confissão informal aos policiais, em estado flagrancial por armazenar mais entorpecentes, em grande quantidade, dentro do imóvel.

Com efeito, a imputação de guardar/armazenar drogas, para fins de comercializar junto a terceiros, consiste em um dos muitos núcleos verbais descritos como ação típica do delito de tráfico (art. 33), também conhecido por crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, diante do elevado número de comportamentos típicas descritas em um só tipo penal.

O agente, repise-se, pode vir a ser preso se for surpreendido cometendo qualquer uma das condutas elencadas como delituosa.

Certo está que a Constituição Federal dispõe ser a casa o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito e em determinadas outras hipóteses (art. 5º, XI), assim como, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente (art. 5º, LXI).

Desta feita, conjugando ambos os dispositivos constitucionais, verifica-se a legalidade do ingresso dos policiais, assim como a prisão do réu, surpreendido, naquele momento, guardando significativa quantidade de droga.

E, pese a linha argumentativa trazida pela D. Defensora, certo está que a imposição coletiva vinculante quanto a necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinada pelo voto monocrático de lavra do E. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz (6ªT do C. STJ) em sede de HC nº 598.051/SP, foi ANULADA pela r. decisão exarada pelo Exmo. Ministro do C. STF, Alexandre de Moraes, ao tempo do julgamento do RE nº 1.342.077, em 02/12/2021.

É certo que a prova oral colhida durante a instrução se baseia, principalmente no depoimento dos policiais que atuaram na ocorrência, mas, vem sendo pacificada na repulsa nas Egrégias Cortes, com lastro do maior quilate na Superior Instância e na Extraordinária em especial, quanto a alegação de imprestabilidade dos depoimentos dos policiais que participam da diligência que culmina com a apreensão de entorpecentes.

Tal insistência visa ressuscitar uma velharia nociva prejudicial, destinada a neutralizar o esforço até patriótico na luta contra as drogas, em recalcitrar, atribuindo-se ao Estado, a desinteligência de conferir a tais agentes o encargo

importantíssimo de coibir o crime, mas, lhes recusar credibilidade para testemunhar.

Ademais, não se provou, nem se invocou com concretude, algo em que se baseasse alguma das hipóteses de válido repúdio a ditos testemunhos, a inverossimilhança ou o entrechoque com outras provas.

Então, concluo serem válidos e plenamente eficazes os depoimentos ofertados pelos policiais que efetuaram o diligenciamento criminoso, haja vista não contarmos com informações que desabonem ou desprestigiem suas condutas e formas de atuação.

Destarte, inviável o pedido de absolvição, sobretudo devido a quantidade e forma de embalagem das drogas.

É certo que o fato de o réu não ter sido preso “vendendo” a droga é matéria irrelevante para a configuração do tipo penal em questão, conforme jurisprudência torrencial a respeito, pois o entendimento francamente vencedor é no sentido de que o perigo de dano em tais casos é presumido de modo absoluto, tendo em vista o perfeitamente conhecido efeito lamentável causado pelo traficante de drogas.

É evidente que o tráfico de entorpecentes envolve atividades essencialmente clandestinas, daí a razão da não exigência da prova flagrancial do comércio ilícito, mas elementos, concretos, que forneçam a evidência do comércio.

Nesse sentido é firme o entendimento jurisprudencial desde a época da Lei 6.368/76:

“Para a configuração do crime previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (hoje 33, caput, da Lei 11.343/06), não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a traditio para consumação do delito” (TJSP – RL. Des. Denser de Sá – RJTJESP vo. 97/512).

Outrossim, já se decidiu que “para formação do juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de agente devidamente processado, não é indispensável à prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente...” (Tribunal de Justiça de Santa Catarina, APL n. 21.376, Rel. Ernani Ribeiro – “JC”, vol. 53/464).

Sendo assim, as circunstâncias fáticas e a prova oral colhida se mostram suficientes para a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes, não havendo campo para a desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal (artigo 28, caput, da Lei 11.343/06), pena de se afrontar à prova dos autos e a boa atuação dos policiais.

E como também reconhecem os tribunais:

"Não cabe a desclassificação do delito de tráfico ilícito de substância entorpecente, para o delito de uso indevido, quando ausente a prova, a cargo da defesa, da exclusividade do uso próprio." (RT 710/325).

Aliás, é sabido que a condição de usuário veiculada, sequer comprovada nos autos, não exclui, a priori, por si só, a de traficante, somente se aplicando a desclassificação quando os elementos permitirem cabal aferição nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese.

Isto porque, é do conhecimento de todos que usuários acabam se enveredando para a prática do crime tráfico, porque visualizam maior facilidade na obtenção de recursos financeiros, além de, claro, receberem drogas como forma de pagamento para

satisfazerem o vício.

Lembro, ademais, que, já contando com histórico anterior de detenção em flagrante (autos nº 1501024-93.2018.8.26.0022 - fl. 220), aproximadamente 02 anos após ser solto nos presentes autos, NILO foi novamente detido em flagrante, sob a acusação de tráfico, sendo, ao final (recentemente), condenado nos respectivos autos (nº 1500236-40.2022.8.26.0022)

O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal por este delito são medidas que se impõem.

PASSO À DOSAGEM DA PENA.

Atento às diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal e da análise da sua Certidão de Evento (fls. 220/221), verifico que os apontamentos nela constantes não traduzem maus antecedentes. Da mesma forma, à luz do art. 42 da Lei de Drogas não evidencio a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a pena-base poderá permanecer no mínimo legal.

Ausentes agravantes e/ou atenuante.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou de diminuição de pena - figura do tráfico privilegiado do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Justifico.

O acusado contava com 51 anos de idade e não desfrutava de vínculo de trabalho fixo e lícito (fl. 13), dedicando-se, por conseguinte, ao tráfico. Justifico.

Observe-se ter sido detido em flagrante aos 26.09.2018 na Rua Rondônia, localizada no Jardim Brasil, sendo solto em 27.09.2018 (fl. 96), mas em 05.05.2020 tornou a ser preso flagrante, novamente no mesmo logradouro, sendo, agora, solto em 16.05.2020 (fl. 220).

Contudo, não cessou seu envolvimento com o tráfico, na medida em que em 24.03.2022 foi detido em flagrante na Rua Santa Catarina, também pertencente ao Jardim Brasil - as ruas são nominadas por Estados do Brasil - sendo ao final condenado, ainda sem trânsito em julgado

Em suma, nos últimos quatro anos foram três prisões em flagrantes, todas por tráfico de entorpecentes, sendo ele pessoa conhecida nos meios policiais.

Anoto que a "dedicação a atividades criminosas" não depende de fatores como a reincidência ou os maus antecedentes.

Nesse sentido:

"(...) Não há ilegalidade na dosimetria da pena, pois, não obstante o paciente seja primário e possuidor de bons antecedentes, o Tribunal estadual afastou a aplicação da causa especial de diminuição, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, as quais o levaram a concluir que o acusado se dedicava a atividades delituosas, notadamente ao narcotráfico (...)" (STJ HC 297406 SP2014/0150910-1, 6ª T., rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 16.10.2014).

Ademais, a quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes (fl. 33), alinhada à informação por ele veiculada no sentido de que tinha por hábito guardar drogas para "Rafael", bem como as circunstâncias do crime, demonstram que o acusado

estava envolvido naquela prática, a ela se dedicando.

Ademais: "(...) Na falta de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do delito, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, para afastar a aplicação da minorante (...)" (HC 434.921/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018).

No que tange ao regime penitenciário, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 11.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffi.

Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §2º e 3º do Cód. Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei (STJ HC 272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6ª Turma J. 10.12.2013).

E, no caso em testilha, atento ao seu histórico comportamental o tempo e a forma com que se desenvolvia a comercialização das drogas, o regime para cumprimento da pena privativa de liberdade, não pode ser outro que o inicial FECHADO.

Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social, principalmente no caso do réu preso em flagrante três vezes nos últimos quatro anos, sob a acusação de tráfico. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.

Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de tráfico ilícito de substância entorpecente desvitaliza a eficácia intimidante da pena, tornando-a inócua.

Pode o juiz determinar o cumprimento da pena em regime fechado, tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, §3º, do CP .

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o réu NILO MINEIRO FILHO, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (duzentos e cinquenta) dias-multas, à razão do mínimo legal, em face da hipossuficiência econômica, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

INCABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, frente a quantidade de pena imposta (art. 44, I, do CP), bem como em razão desse julgador compartilhar o entendimento no sentido de que o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, não estar preenchido: "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente".

O réu foi solto no decorrer do presente feito, por força de decisão exarada pelo E. TJSP (fls. 98/100).

Menos de dois anos depois - e considerando que durante esse houve severas restrições vivenciadas pela Covid-19, especialmente recolhimentos domiciliares - tornou a ser preso em flagrante, em 24.03.2022, novamente pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo, ao final, condenado em primeira instância - está atualmente recolhido em estabelecimento prisional. Traiu a confiança que lhe foi concedida pela Instância Superior, sinalizando, concretamente, que, em liberdade, adota comportamento aviltante, perturbador da ordem pública ao promover/fomentar a

comercialização de drogas.

Ademais, no presente caso, suportou decreto condenatório, a ser cumprido em regime prisional mais gravoso.

Então, presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, em especial à aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública (art. 312, caput e §2º, do CPP), DECRETO a prisão preventiva do acusado, vedando-lhe aguardar em liberdade eventual a fase recursal (art. 387, §1º, CPP).

Expeça-se imediato mandado de prisão.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas que ainda não tenham sido incineradas, oficiando-se.

Declaro o perdimento dos valores em espécie apreendidos - fl. 115 (art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06), em favor da União.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

P.R.I.C.

Amparo, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA